

[문제-1]	
I. 설문(1)	
1. 문제의 소재 0.5	
	대위소 계속 중 채무자 丙이 대위소에 참가하는 경우 대위채권자와의 관계 및 소송요건에 따라 공동소송적 보조참가 할지 논한다.
2. 대위소의 법적 성질 1.5	
(1) 학설 및 判例	
	1)통설 및 判例인 법정소송담당설은 채권자가 채무자에 대한 권리 보전을 위해 채무자를 대위해 채무자의 제3채무자에 대한 권리를 행사하는 것이라고 한다.
	2)고유대위권설은 대위소를 채권자가 자신의 이익을 위해 민법이 그에게 인정한 고유의 대위권을 행사하는 것으로 본다.
(2) 검토	
	대위권 행사 효력이 채무자에게 귀속됨에 비추어 판시 타당하다.
3. 대위소에 채무자가 참가하는 경우 소송참가 형태 4	
(1) 학설 i)보조참가설은 고유대위권설 입장에서 채무자는 대위소 기판력을 받지 않는바 보조참가만 가능하다고 한다. ii)공동소송적보조참가설은 담당설 입장에서 채무자는 대위소 기판력 받지만 중복소에 해당하여 소송요건 흠결인바 공동소송적 보조참가한다고 한다. iii)공동소송참가설은 담당설 입장에서 채무자는 대위소 기판력 받으며 참가는 소송경제가 도모되고 판결모순 우려도 없어 중복소제기금지에 반하지 않아 공동소송참가 가능하다고 한다.	

(2) 判例	
채권자가 대위소 제기하고 판결 받으면 채무자가 대위소 제기사실을 안 때 판결효가 채무자에게 미치고 채무자에게 고지 등의 방법으로 필요에 따라 공동소송적 참가, 기타의 방법으로 고유의 권리를 보호할 기회 주어야 한다고 한다.	
(3) 검토	
채무자는 대위소송에서 대위채권자와 합일확정 요청되는 관계이며 소송경제 도모 및 판결모순 우려 없어 중복소제기에 비해당되지만 대위소 제기 사실을 알면 피대위채권 이행청구할 당사자적격 상실하므로 공동소송적 보조참가 가능하다고 봄이 타당하다.	
4. 사안해결 - 공동소송적 보조참가 1.5	
(1) [제78조] 판결효가 제3자에게 미치는 경우, 소송절차에 공동소송적 보조참가할 수 있다. 자기이익 지킬 기회 부여 위함이다.	
(2) 丙은 i)甲, 乙, 丁의 대위소 계속 중 ii)대위소 제기사실을 알아 대위소의 판결효를 받게 되어 합일확정 요구되며 iii)피대위채권 이행의 소 당사자적격 상실한바 공동소송적 보조참가 할 것이다.	
II. 설문(2)	
1. 문제의 소재 0.5	
甲, 乙이 대위채권자로서 필수적 공동소송관계인지 검토하여 1인 甲의 항소로 乙이 함께 이심되는지 여부 및 乙의 지위를 논한다.	
2. 甲과 乙의 공동소송 형태 2.5	
(1) 공동소송형태	

	필수적 공동소송은 합일확정 요청에 따라 공동소송인 상호간 판결 효 미치는 형태의 공동소송이다.
(2)	대위소 기판력이 다른 대위채권자에게 미치는지 여부
	i) 기판력설, 반사효설, 부정설 있으나 ii) 判例는 어떤 사유로든 대위소 제기사실을 채무자가 안 경우 판결효가 채무자에게 미치므로 다른 채권자가 동일 소송물에 대해 채권자 대위권에 기한 소 제기하면 전소 기판력을 받는다고 한다.
(3)	사안
	甲, 乙은 대위채권자로 丙이 대위소 제기 사실을 아는바 서로 간에 판결효력이 미치고 합일확정 요구되어 필수적 공동소송관계다.
3. 필수적 공동소송 심판방식 - 상소 2	
(1)	원칙 - 연합관계 [제67조]
	상호 연합관계가 있어 합일확정 요청되고 판결의 통일을 요한다.
(2)	상소불가분원칙 의의 및 취지
	상소에 의한 확정차단 및 이심효력은 원판결 전부에 미친다. 상소심에서의 심판범위 확장 기회 보장하기 위함이다.
(3)	사안
	제67조에 따라 甲항소시 乙도 확정차단되고 항소심으로 이심된다.
4. 항소하지 않은 乙의 항소심에서의 지위 3	
(1)	학설 i) 상소하지 않은 자도 상소인으로 보는 견해 ii) 상소하지 않은 자들이 상소인에게 묵시적으로 소송수행권 부여한 것으로 보아 선정자의 지위를 갖는다는 견해 iii) 합일확정 위해 그들도

	상소심으로 이심되어 상소심당사자가 된다는 견해가 있다.
(2) 判例	
	항소하지 않은 공동소송인을 항소심 당사자로 표시한 것이 있다.
(3) 검토 및 사안	
	i) 생각건대 상소하지도 않은 자를 상소인으로 볼 수 없고 선정
	행위가 없었는바 선정자로 볼 수도 없어 상소심당사자설 타당하
	다. ii) 사안에서 甲의 항소로 함께 항소심으로 이심된 乙은 항소
	심 당사자의 지위를 갖는다.
(4) 상소심 당사자의 지위	
	상소인지, 상소비용 부담하지 않고 상소취하권도 없다.
5. 사안해결 0.5	
	甲의 항소로 상소불가분원칙에 따라 乙도 항소심으로 이심되고
	乙은 항소심당사자의 지위를 가지며 항소인지, 항소비용 부담하지
	않고 항소취하권도 없다.
Ⅲ. 설문(3)	
1. 문제의 소재 1	
	丁과 戊가 주관적 예비적 병합관계에 있는지 검토 후 그 심판방
	식에 일부판결이 적법한지, 1인 丁이 항소하였을 때 항소심으로
	함께 이심되어 심판대상이 되는지 검토한다.
2. 주관적 예비적 병합 해당 여부 2	
(1) 의의·취지 및 허용 여부 [제70조 1항]	
	i) 공동소송인 가운데 일부에 대한 청구가 다른 공동소송인에 대

	한 청구와 법률상 불가능한 경우 제67조 내지 제69조 준용한다.
	ii)반대견해 있었으나 02개정법은 제70조 2항에서 모든 공동소송인에 대해 판단하여 분쟁의 1회적 해결, 재판통일 도모하였다.
(2)	요건 충족 여부
	判例에 따르면 i)丁, 戊는 戊의 대리권 존부에 따라 丁의 이행의무 인정되고 戊의 이행의무가 부정되거나 丁의 이행의무 부정되고 戊의 이행의무 인정되어 법률상 양립불가능한 관계이며 ii)공동소송요건 갖추었다고 보여지는바 주관적 예비적 병합이다.
3.	丁의 항소로 戊도 이심되어 심판대상이 되는지 여부 2.5
(1)	[제70조 1항 및 2항]
	i)제67조 내지 제69조 준용한다. 취하, 포기, 인낙, 화해는 각자 할 수 있다. ii)법원은 모든 공동소송인에 대해 심판한다.
(2)	심판방식
	i)판결 통일 요하며 ii)1인 상소시 전원 확정차단되어 상소심으로 이심되고 상소하지 않은 자의 부분도 항소심 심판대상이 된다.
(3)	사안
	제67조에 따라 합일확정 요청 있는바 상소불가분원칙에 따라 丁 항소로 戊도 항소심으로 이심되고 戊 부분도 심판대상이 된다.
4.	1심판결의 위법성 - 일부판결 가부 1.5
(1)	判例
	예비적 공동소송에서 일부 공동소송인에 관한 청구만 판결하면 이는 일부판결이 아닌 흠이 있는 전부판결에 해당한다.

(2) 사안
1심은 丁에 대해서만 판단하고 戊에 대해 판단하지 않아 이는 일부판결이 아닌 흠이 있는 전부판결이다.
5. 사안해결 1
丁의 항소로 戊도 이심되어 심판대상되며 1심판결은 위법한 전부판결인바 직권으로 취소하고 1심과 동일한 심증 들었다면 丁에 대해 청구인용 戊에 대해 청구기각한다.
[문제-2]
I. 설문(1)
1. 문제의 소재 - 서증 의의 및 취지 1
i)서증이란 문서에 표현된 의사를 증거자료로 하여 요증사실을 증명하는 증거조사이다. ii)乙은 인영의 위조 및 제3자의 인장도 용을 주장하는바 인부절차, 2단의 추정 및 복멸의 법리 검토한다.
2. 문서의 진정성립 의의 및 판단 1
(1) 문서가 문서신청자에 의해 작성자로 주장되는 자 의사에 기해 작성된 것 말한다. 진정성립 인정된 문서는 형식적 증거력이 있다.
(2) 인정, 침묵, 부인, 부지의 인부절차 및 변론전취지에 따라 자유심증으로 판단한다.
3. 사문서인 계약서의 진정성립 추정 및 복멸 여부 4
(1) 추정 - 2단의 추정
1)[제357조] 제출자는 사문서가 진정한 것임을 증명해야 한다.

2)判例는 인영의 진정이 인정되면 날인의 진정이 사실상 추정되고,	
날인의 진정이 인정되면 문서 전체의 진정성립이 제358조에 의해	
유사적 추정된다고 하여 2단의 추정을 인정한다.	
(2) 인영의 진정 복멸	
인영의 진정은 법관이 의심을 품게 하는 반증으로 복멸한다.	
(3) 날인의 진정 복멸	
i)判例는 날인의 진정 추정은 사실상 추정이므로 날인의 진정을	
다투는 자가 반증을 들어 날인의 진정에 관해 법관으로 하여금	
의심을 품게할 사정을 입증시 추정 깨진다고 한다.	
ii)인장도용, 강박날인, 자격모용 사실을 본증으로 제출하여 날인	
의 진정을 간접반증으로 복멸시킬 수 있다.	
(4) 제3자의 인장도용이 인정된 경우	
날인의 진정은 사실상 추정으로 작성명의인 이외의 자에 의해 이	
루어진 것이 밝혀지면 깨지므로 문서제출자는 날인행위가 작성명	
의인으로부터 위임받은 정당한 권원에 의한 것이라는 사실을 입	
증해야 한다.	
4. 사안해결 2	
(1) 확인서는 사문서인바 제357조 및 2단의 추정이 적용된다. 인영의	
진정은 반증으로 복멸시킬 수 있고 날인의 진정은 인장도용을 본	
증으로 제출해 간접반증으로 복멸시킬 수 있다.	
(2) 乙이 인영의 진정을 부인하고 있으므로 甲은 인영의 진정을 인정	
받기 위한 증거를 제출하거나 乙의 의사로 날인사실을 증명한다.	

	(3) 乙의 인장도용 주장을 반증으로 법관이 의심을 품게 하거나 그자
	가 乙로부터 정당한 권원을 위임받아 날인한 것임을 증명한다.
	II. 설문(2)
	1. 문제의 소재 1
	상속인이 있는 甲이 제소전 사망하고 그가 선임한 소송대리인 A
	가 소제기한 경우 취급 검토하여, 제소전 사망자가 원고임에도 그
	가 선임한 소송대리인의 소제기가 적법한지 논한다.
	2. 제소전 사망 취급 1.5
	(1) 당사자 확정
	i)의사설, 표시설, 행동설 있으나 ii)判例는 실질적 표시설에 따
	라 당사자로 표시된 사망자가 당사자로 확정됨이 원칙이나, 보정
	하는 경우 상속인을 당사자로 확정하여 표시정정 허용한다.
	(2) 법원의 조치
	대립당사자주의 취하는 민사소송에서 당사자능력은 소송요건이며,
	제소전 사망자가 당사자인 경우 소송요건을 갖추지 않은 것으로
	부적법하여 소각하된다.
	3. 소송대리인 선임 후 제소전 사망한 경우 소의 적부 4.5
	(1) [제95조] 당사자가 사망하더라도 소송대리인의 소송대리권은 소
	멸하지 않는다.
	(2) i)[제233조] 당사자가 사망시 소송절차는 중단되며 상속인 등이
	절차를 수계하여야 한다. ii)[제238조] 다만, 당사자 사망시 소송
	대리인이 있으면 절차 중단되지 않는다.

(3) 判例	
당사자가 소송대리인에게 소송위임하고 소제기 전 사망했는데 소송대리인이 당사자가 사망한 것을 모르고 그를 원고로 표시하여 소를 제기하였다면 소제기는 적법하고 시효중단 등 소제기 효력은 상속인에게 귀속된다. 이 경우 제233조 1항이 유추적용되어 사망자의 상속인은 소송절차를 수계한다.	
(4) 학설 i)判例와 같은 견해 있으나 ii)반대견해는 제소전 사망시 대리권이 소멸되어 소가 부적법하고 제95조, 제233조, 제238조는 소송 중 사망한 경우에 적용되므로 제소전 사망은 표시정정으로 처리해야 한다고 한다.	
(5) 검토 및 사안	
i)생각건대 소송대리인 위임은 제소전에도 가능하고 제95조는 본인 사망시에도 소송대리권 소멸을 부정하는바 판시 타당하다.	
ii)사안에서 甲이 A에게 소송위임하고 제소전 사망한 다음, A가 甲의 사망을 모르고 그를 원고로 표시해도 소제기는 적법하다.	
4. 사안해결 0.5	
제소전 사망자 甲을 원고로 한 소송대리인 A의 소제기 적법하다.	
[문제-3]	
I. 설문(1)	
1. 문제의 소재 0.5	
乙은 X건물이 甲의 소유라고 인정하여 자백이 성립했다고 볼 여	

	지가 있는바 소유권을 인정하는 진술이 자백인지, 자백이라면 철회의 제한이 있는지 검토한다.
2. 자백의 의의 및 효과 1	
(1)	자백이란 상대방 주장사실과 일치하고 자신에게 불리한 주요사실에 대한 진술이다.
(2)	자백성립시 제288조 불요증사실이 되어 법원, 당사자 구속하고 자백이 성립된 내용대로 사실인정한다.
3. 소유권에 대한 자백 성립 여부 4.5	
(1) 문제점	
	자백은 사실에 대해 성립한다. 소유권에 기한 건물인도청구에서 선결적 법률관계에 자백이 성립하는지 문제된다.
(2) 判例	
i)	소송물 전제가 되는 권리관계를 인정하는 진술은 권리자백으로 법원 기속하지 않고 상대방 동의 없이 자유로이 철회가능하다.
ii)	다만, 피고가 원고의 소유권을 인정한 진술은 그 소전제가 되는 소유권의 내용을 이루는 사실에 대한 진술로 볼 수 있어 재판상 자백이다.
(3) 학설 i)	긍정설은 소유권과 같은 선결적 법률관계가 중간확인 의 소의 소송물이 되었을 때 인낙이 가능한바 소유권에 대한 자백도 허용된다고 한다. ii) 부정설은 권리자백은 법원의 전권인 법률판단에 관한 자백이므로 자백 효력이 없다고 한다.
(4) 검토 및 사안	

	i)생각건대 요건사실에 대해선 자백 성립 가능하고 요건사실은 법률효과 발생시키는 구체적 사실을 의미하므로 소유권 인정 진술은 권리 자체가 아닌 그를 이루는 구체적 사실에 대한 내용을 인정하는 것으로 볼 것이다. ii)사안에서 乙이 X건물이 甲소유라고 인정하면 소유권을 이루는 사실을 인정하는 자백으로 볼 수 있다.
4. 소유권을 인정한 자백 철회 가부 2	
(1) 자백 철회의 제한	
	자백은 여효적 소송행위로 직접 소송상 효력이 발생해 절차안정, 상대방 신뢰보호 위해 원칙적으로 철회 불가하다.
(2) 예외	
	다만, i)자백에 5호 재심사유 있을 때 ii)자백취소에 상대방이 동의한 때 iii)자백이 진실에 반하고 착오에 기한 것일 때 iv)소송대리인의 자백에 대해 경정권 행사할 때에는 철회 가능하다.
(3) 사안	
	乙의 X건물 소유권 이루는 사실에 대한 자백 성립했고 철회사유 없는바 절차안정, 상대방 신뢰보호상 철회할 수 없다.
5. 사안해결 0.5	
	乙진술은 자백이며, 이후 甲이 X건물 소유권 없음 주장 불가하다.
II. 설문(2)	
1. 문제의 소재 0.5	
	쌍방불출석 취하간주의 횡수 산입과 관련하여 예비적 절차인 변론준비절차의 불출석과 변론기일 불출석 횡수를 합산하여 계산하

	는지 여부를 검토한다.
2. 쌍방불출석취하간주 2	
(1) 의의 및 취지 [제268조]	
	적법한 기일통지를 받고도 양쪽 당사자가 변론기일에 불출석하거나 무변론인 경우, 2회 내지 3회 불출석일 경우, 취하간주 처리된다. 소송의사 없는 소송의 조기종료 위함이다.
(2) 요건	
	i) 양측의 1회 불출석 또는 무변론일 것 ii) 이후 새 변론기일에 서 양측의 불출석 또는 무변론일 것 iii) 당사자가 1월 이내에 기일지정신청을 하지 않거나 이후 변론기일에서 3회 불출석 또는 무변론인 경우이어야 한다.
(3) 효과	
	소취하, 상소심에서는 상소취하 간주로 처리한다.
3. 변론준비기일 불출석 효과가 변론기일에 승계되는지 여부 4	
(1) 변론준비절차 의의 및 취지 [제286조]	
	변론의 효율적 진행을 위해 변론기일 전에 사실, 증거를 정리하는 사전적, 예비적 절차이다.
(2) 학설 i) 제286조에서 제268조를 준용하고 있으므로 변론준비기일 실효성을 위해 승계된다는 견해 ii) 변론기일과 변론준비기일은 운영주체와 방식이 달라 승계 부정하는 견해 있다.	
(3) 判例	
	변론준비기일은 재판장에 의해 비공개로 진행되어 직접주의, 공개

	주의가 후퇴할 수 있고 취하간주제도는 적극적 당사자에게 불리한 제도인바 불출석 효과는 변론기일에 승계되지 않는다.
(4) 검토 및 사안	
	i) 생각건대 소취하간주 규정은 헌법상 재판받을 권리 침해 우려 없어 명문규정 없이 확대 적용할 수 없다. ii) 사안에서 甲, 乙은 변론준비절차에서 모두 불출석 했으나 이는 변론기일로 승계되지 않고 쌍방불출석 취하간주 횡수 산입에 포함되지 않는다.
4. 사안해결 0.5	
	변론준비절차에서 불출석은 변론기일에 승계되지 않는바 이후 변론기일 불출석, 무변론이어도 2회 불출석으로 취급되지 않는다.
III. 설문(3)	
1. 문제의 소재 0.5	
	甲과 乙이 2회 불출석 또는 무변론인바 쌍방불출석 취하간주 제도와 관련하여 법원이 직권으로 기일을 지정할 것인지, 변론을 종결하고 판결을 선고할 수 있는지 검토한다.
2. 쌍방불출석 취하간주의 요건 2.5	
(1) 양측의 1회 불출석 또는 무변론일 것	
	이 경우 법원은 양쪽 당사자에게 다시 기일통지를 한다.
(2) 양쪽 당사자의 2회 결석 또는 출석했더라도 무변론일 것	
	법원은 변론을 종결하거나 신기일을 정하지 않고 당해 기일을 종료시킬 수 있다.
(3) 당사자가 1월 이내에 기일지정신청을 하지 않거나 이후 변론기일	

	에서 3회 불출석 또는 무변론일 것
	1월의 기간은 불변기간이 아니어서 기일지정신청의 추후보완은 불가하며, 제268조에 의해 소 또는 상소를 취하간주처리 한다.
	3. 2회 불출석 또는 무변론 후 직권으로 기일지정 가부 및 취급 2
	(1) 의의 [제165조 1항]
	기일은 직권 또는 당사자의 신청에 따라 재판장이 지정한다.
	(2) 효과
	i)법원의 직권 기일 지정은 당사자의 기일지정신청에 의한 기일 지정과 마찬가지로의 효과를 갖는다. ii)이후 직권으로 지정된 기일에 불출석 또는 무변론시 소취하간주될 수 있다.
	(3) 사안
	재판장은 직권으로 제3회 변론기일 지정가능하며 甲, 乙이 재차 불출석 또는 무변론시 소취하간주 될 수 있다.
	4. 2회 불출석 또는 무변론 후 변론종결하고 판결 선고 가부 2
	(1) 1회 불출석 또는 무변론인 경우
	i)소송촉진을 위해 반대견해 있으나 ii)명문의 규정에서 당사자에게 기일통지를 한다고 규정한바 변론종결하고 판결할 수 없다.
	(2) 2회 불출석 또는 무변론인 경우
	i)절차권 보장 위해 반대견해 있으나 ii)명문의 규정에서 기일 통지를 한다는 규정이 없어 변론종결 후 소송기록에 의해 판결할 수 있다.
	(3) 사안

	甲, 乙이 2회 불출석 또는 무변론인바 법원은 변론종결 후 소송기록에 의해 판결을 선고할 수 있다.
5. 사안해결 0.5	
	법원은 직권으로 기일지정하거나 변론종결 후 판결할 수 있다.
[문제-4]	
I. 설문(1)	
1. 문제의 소재 0.5	
	1심에서 乙의 상계항변 받아들여 일부인용판결 선고된 바, 乙이 항소의 대상으로 삼을 수 있는 범위에 대해 상계항변과 관련된 상소이익 판단기준을 통해 검토한다.
2. 상소이익의 의의 및 판단기준 3.5	
(1) 의의 및 취지	
	하급심 판결의 취소변경을 구할 수 있는 이익이다. 남상소 방지를 위한 상소요건으로 함결시 항소각하한다.
(2) 판단기준	
1)학설 i)형식적불복설은 신청보다 판결 주문이 불리한 경우 상소이익 인정해 전부승소시 상소할 수 없다고 한다. ii)실질적불복설은 전부승소한 자라도 실제법상 더 유리한 판결 받을 수 있다면 상소이익 긍정한다. iii)절충설 iv)신실질적 불복설도 있다.	
2)判例 [불불주형]	
	상소인은 자기에게 불이익한 재판에 대해서 상소할 수 있고, 불이

	익함은 주문을 표준으로 결정된다 하여 형식적 불복설 입장이다.
	3)검토 및 사안
	i)실질적불복설은 상소 허용범위가 너무 넓고, 절충설은 당사자
	평등에 반하므로, 형식적불복설이 타당하다. ii)사안에서 ①乙은
	주문상 패소한 4000만 원 부분에 대해 항소이익이 있어 항소할
	수 있다. ②乙의 상계로 주문상 승소했다고 볼 수 있는 일부기각
	된 6000만 원 부분에 대해서도 乙이 항소할 수 있는지 문제된다.
	3. 상계주장이 받아들여진 부분에 대한 피고의 상소이익 3
	(1) [제216조 2항] 판결이유 중 상계항변에 대한 판단에 기판력 발생
	한다. 채권이중행사 방지 및 판결무용화 방지 위함이다.
	(2) 判例
	원고의 청구원인 모두 인정 후 피고의 상계항변 받아들여 상계
	후 잔존하는 원고의 나머지 청구 부분만 일부인용한 경우 피고는
	판결이유 중 원고 소구채권을 인정하는 전제에서 상계항변이 받
	아들여진 부분에 관하여도 상소할 수 있다.
	(3) 사안
	甲의 1억 원 물품대금청구가 인정된다는 전제 하에 乙의 6000만
	원 손해배상채권에 기한 상계 받아들여 4000만 원 일부인용한 판
	결에 대해 乙의 상계가 받아들여진 6000만 원 부분에 대해서 항
	소할 수 있다.
	4. 사안해결 0.5
	乙은 청구 전부에 대해 항소할 수 있어 항소의 대상이 될 수 있

	는 최대 금액은 1억 원이다.
II. 설문(2)	
1. 문제의 소재 0.5	
	乙의 상계항변에 대해 甲이 乙을 상대로 5000만 원의 상계재항변을 한바 상계 재항변이 가능한지 검토하여 법원이 최종적으로 인용할 금액을 판단한다.
2. 소송상 상계항변의 법적 성질 1	
	判例는 상계항변은 소송상 방어방법으로 수동채권의 존재가 확정되는 것을 전제로 행하여지는 일종의 예비적 항변으로 의사표시에 의해 확정적으로 효과가 발생하는 것이 아니라 수동채권의 존재 등 상계에 관한 실질적 판단이 이루어질 때 실제법상 상계의 효과가 발생한다고 한다.
3. 상계항변에 대한 상계재항변 가부 5	
(1) 判例	
	i)법원이 피고의 소송상 상계항변 배척하는 경우 소송상 상계의 재항변을 판단할 필요가 없다.
	ii)피고의 소송상 상계항변이 이유 있는 경우 수동채권과 자동채권이 상계적상 당시에 대등액에서 소멸한 것으로 본다. 원고가 상계의 재항변으로써 상계할 대상인 피고의 자동채권이 그 범위에서 존재하지 않는 것이 되어 이때에도 원고의 상계 재항변을 판단할 필요가 없다.
	iii)원고의 상계 재항변은 일반적으로 허용할 이익이 없다.

(2) 검토 및 사안

i) 생각건대 원고가 별도의 채권을 갖는 경우 추가적 병합 또는 별소로 이를 구할 수 있는바 심리 간명화 위해 상계 재항변은 불허함이 타당하다.

ii) 사안에서 ①피고 乙의 상계항변이 배척되는 경우 원고 甲의 상계재항변을 판단할 필요가 없다. ②乙의 상계항변이 이유 있는 경우 수동채권인 소송물 1억 원 대금지급청구권과 대등액 6000만 원 범위에서 소멸하게 되므로 甲이 상계재항변으로 상계할 대상인 乙의 손해배상채권이 존재하지 않아 甲의 상계재항변을 판단할 필요가 없다.

4, 사안해결 1

甲의 5000만 원 대여금채권에 기한 상계재항변은 판단할 필요가 없으며 甲의 소구채권 1억 원과 乙의 상계 자동채권 6000만 원 모두 인정되므로 대등액에서 소멸된 후 잔존하는 甲의 4000만 원을 인정하는 일부인용판결을 선고한다.

- 이 하 여 백 -